

刑法
No177

共通問題 H24-2

(配点: 3)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、甲に()内の犯罪の共同正犯が成立する場合には1を、教唆犯又は幫助犯が成立する場合には2を、間接正犯が成立する場合には3を選びなさい。

- ア. 甲は、甲の所属する暴力団事務所にVを連行し、同事務所において3日間、Vを逃走できないように見張って監禁し、その後、同じ暴力団に所属する乙に対して「お前が俺に代わって見張れ。」と言った。乙は、これを了承し、4日目から前記事務所においてVを逃走できないように見張って監禁した。5日目に乙が居眠りをした際に、Vは、前記事務所の窓から外に飛び降りて逃げ出したが、飛び降りた際、右足首を骨折した。(監禁致傷罪)
- イ. 甲は、乙が自宅で賭博場を開張して利益を得ていることを知り、乙の役に立とうと考え、乙に連絡することなく、乙の開張する賭博場にA及びBを誘引し、賭博をさせた。(賭博場開張図利罪)
- ウ. 甲は、常日頃暴行を加えて自己の意のままに従わせていた実子の乙(13歳)に対し、Vが管理するさい銭箱から現金を盗んでくるように命じ、乙は、是非善悪の識別能力及び識別に従って行動を制御する能力を有していたが、甲の命令に従わなければまた暴力を振るわれると畏怖し、意思を抑圧された状態で、前記さい銭箱から現金を盗んだ。(窃盗罪)
- エ. 甲は、知人乙から、交際相手であるVを殺害したいので青酸カリを入手してほしいと依頼され、自らもVに恨みを抱いていたことから、青酸カリを準備して乙に交付した。乙は、甲から青酸カリを受領した後、実行行為に出る前にV殺害を思いとどまり、警察署に出頭した。(殺人予備罪)
- オ. 甲は、乙から、乙がV方に強盗に入る際に外で見張りをしてほしいと頼まれ、利益を折半する約束でこれを承諾し、乙と共にV方に赴いた。甲がV方の外で見張りをしている間に、乙はV方に侵入した。その後、甲は、不安になり、携帯電話で乙に「やっぱり嫌だ。俺は逃げる。」と告げた上、その場から逃走した。乙は、甲の逃走を認識した後、V方内にいたVを発見し、同人に包丁を突き付けてその反抗を抑圧した上、現金を強取した。(強盗罪)

No177

共犯一般の区別

正答率

51%

共通H24-2

正解

ア 1 イ 2 ウ 3 エ 1 オ 1

ア 共同正犯が成立する

最判昭 23.12.14。共同正犯が成立するためには、原則として①共同実行と②意思の連絡があることが必要であるところ、本記述では、甲が乙に対してVの見張りを命じたことと乙のその了承により②意思の連絡が認められるかが問題となる。判例は、意思の連絡の有無が問題となった事案において、「共同正犯たるには、行為者双方の間に意思の聯絡のあることは必要であるが、行為者間において事前に打合せ等のあることは必ずしも必要ではなく、共同行為の認識があり、互に一方の行為を利用し全員協力して犯罪事実を実現せしむれば足るのである。」としている。本記述では、甲は乙との事前の打ち合わせなくVを監禁していたものであるが、Vを監禁していたのは暴力団事務所であり、乙は同組に属する暴力団員であったのだから、Vの見張りを命じられ、乙もこれを了承したことによって、共同行為の認識があり、互に一方の行為を利用し全員協力して犯罪事実を実現したといえ、共同意思の連絡を認めることできる。したがって、甲に監禁致傷罪の共同正犯が成立する。

イ 幫助犯が成立する

大判大 14.1.22。本記述では、甲は乙に連絡することなく客を誘引していることから、このように意思の連絡なく幫助行為をした場合にも幫助犯が成立するか(片面的幫助の可否)が問題となる。判例は、某所で賭博が行われておりそれによって開張者が利を図っていることを知りながら、賭者を同所へ誘引し賭博をさせ賭博場の開張を幫助した事案において、被告が正犯の賭博開張行為を認識し、これを幫助するために賭者を誘引し賭博させた事実は明白であり、被告の従犯としての主観的及び客観的要件に何らの不備があるとはいえず、従犯者と正犯との間には、相互的な意思連絡があることを必要とせず、正犯者が従犯の幫助行為を認識する必要はないとして、賭博場開張罪の幫助を認めた。本記述では、甲は、乙が自宅で賭博場を開張して利益を得ていることを知り、乙の開張する賭博場にAらを誘引し、賭博をさせたというのだから賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。したがって、甲に賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。

ウ 間接正犯が成立する

最決昭 58.9.21 (百選174 事件)。本記述では、乙が是非善悪の識別能力及び識別に従って行動を制御する能力を有する者であったことから、甲には窃盗罪の教唆犯が成立するにとどまり、間接正犯は成立しないのではないかが問題となる。判例は、12歳の養女を連れて巡礼中、巡礼先の寺院等において、同女に命じて次々と窃盗を働かせ、盗んできた金具を巡礼の費用などにあてていた被告人に窃盗罪の間接正犯が成立するかが問題となった事案において、「巡礼中、日頃被告人の言動に逆らう素振りを見せる都度顔面にタバコの火を押しつけたりドライバーで顔をこすつたりするなどの暴行を加えて自己の意のままに従わせていた同女に対し、本件各窃盗を命じてこれを行わせたというのであり、これによれば、被告人が、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行つたと認められるのであるから、たとえ所論のように同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、被告人については本件各窃盗の間接正犯が成立すると認めるべきである。」としている。本記述では、常日頃暴行を加えて自己の意のままに従わせていた実子乙(13歳)に対し、Vが管理するさい銭箱から現金を盗んでくるように命じ、乙は甲の命令に従わなければまた暴力を振るわれると畏怖し、意思を抑圧された状態でさい銭箱から現金を盗んだというのだから、乙が是非善悪の識別能力及び識別に従って行動を制御する能力を有する者であったとしても甲には窃盗罪の間接正犯が成立する。したがって、甲に窃盗罪の間接正犯が成立する。

エ 共同正犯が成立する ★

最決昭 37.11.8 (百選 I 80 事件)。本記述では、甲に殺人予備罪の共同正犯が成立するかが問題となる。判例は、不倫関係にあったZの夫Aを殺害する計画を立てたYが、従兄に当たる被告人Xに青酸カリの入手を依頼したところ、Xはそれを承諾した上で青酸カリを入手して、Yに手渡したが、Yは青酸カリを使用しなかったという事案において、青酸カリを入手しYに手渡したXは、殺人予備の幫助ではなく、殺人予備の共同正犯とすべきであるとした原審の結論を維持している。本記述では、甲は、知人乙から交際相手であるVを殺害したいので青酸カリを入手してほしいと依頼され、自らもVに恨みを抱いていたことから、青酸カリを準備して乙に交付したというのであるから、甲には殺人予備罪の共同正犯が成立する。したがって、甲に殺人予備罪の共同正犯が成立する。

オ 共同正犯が成立する

最決平 21.6.30 (百選 I 97 事件)。本記述では、共犯者が住居に侵入した後、強盗の実行行為に着手する前に現場から離脱した者について、どのような場合に共謀関係の解消が認められるかが問題となる。判例は、被告人が、共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀したところ、共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後、見張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい、先に帰る」などと一方的に伝えただけで、待機していた場所から見張り役らと共に離脱し、残された共犯者らがそのまま強盗に及んだという事案において、「被告人は、共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀したところ、共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後、見張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で『犯行をやめた方がよい、先に帰る』などと一方的に伝えただけで、被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく待機していた場所から見張り役らと共に離脱したにすぎず、残された共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認められる。そうすると、被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識した上で離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということとはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めるのが相当である。」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共謀形成の役割などにもよるが、「共犯者らの強盗が当初の共謀に基づいて行われたものと認めるのか否か」という判断は、着手後の離脱の要件と連続的であり、場合によっては、以後の犯行を防止する措置が必要となる場合も考えられることを挙げている。本記述では、甲は、乙がV方に強盗に入る際に外で、見張りをしていることを利益を折半する約束でこれを承諾した者であって、乙がV方に侵入した後に、携帯電話で乙に「やっぱり嫌だ。俺は逃げる。」と一方的に告げ、現場から立ち去ったというのだから、甲には共謀関係からの離脱は認められず、強盗罪の共同正犯が成立する。したがって、甲に強盗罪の共同正犯が成立する。